

釋憲制度改革新議

台灣大學2017/09/20

湯德宗

Dennis T. C. Tang

司法院大法官

The Honorable Justice

Judicial Yuan (Constitutional Court)

Republic of China (Taiwan)

dennistc@judicial.gov.tw

<http://idv.sinica.edu.tw/dennis/>



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」台灣 3.0 版授權釋出】

湯德宗大法官

The Honorable Justice Dennis T. C. Tang

學經歷：

美國紐約大學(NYU)法學院客座特聘教授

中央研究院特聘研究員暨法律學研究所創所所長

國立台灣大學國發所暨政治系兼任教授

日本東京大學(Tokyo U.)法學部客座教授

德國科隆大學(Universität zu Köln)鴻博(AvH)訪問學者

美國杜蘭大學(Tulane U.) 法學博士

(S. J. D.) 美國哈佛大學(Harvard U.) 法

學碩士(LL. M.) 國立台灣大學法律研究所

碩士

國立台灣大學法律系 學士



代表作：

《憲法結構與動態平衡：權力分立新論 卷一》(增訂四版, 2014)

《違憲審查與動態平衡：權力分立新論 卷二》(增訂四版, 2014)

《對話憲法・憲法對話：湯德宗憲法有聲書》(上冊, 增訂三版2015; 下冊, 增訂三版2016)

<http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/105S104>

《行政程序法論：論正當行政程序》(增訂二版, 2005)

ENVIRONMENTAL LAW AND ENFORCEMENT IN THE ASIA-PACIFIC RIM 435~486 (Sweet & Maxwell, 2002).

目次

引言

壹、違憲審查制度

一、目的

二、建置

三、程序

貳、大法官解釋鳥瞰

一、成果

二、困境

參、癥結（診斷）& 對策（處方）

一、不得連任 & 間隔任期

二、大法庭 & 低效率合議

三、人能弘道，非道弘人

四、司法院組織定位

五、違憲審查漏洞

結語

引言

比較憲法宏觀觀察

違憲審查 (constitutional review, judicial review of constitutionality)

= **憲法解釋 (釋憲) 制度**

指由特定機關 (如司法院大法官、憲法法院) 審查並宣告

其他憲法機關之**憲法行為** (憲法職權行使) 有無**牴觸憲法**的制度

回首往事

.....

司法改革委員會 (1994/10)

全國司法改革會議 (1999/07/06~08)

全國司法改革會議 (2017/02~08)

壹、違憲審查制度

一、目的

為何設置大法官解釋憲法？

1. 維護憲法至高性

1.1 **法至高性**(supremacy/primacy of the Constitution,
Vorrang der Verfassung) **法規範階層構造說**
(Stufentheorie)

§170：「本憲法所稱之法律，謂經立法院通過，總統公布之法律」

§171-I：「**法律與憲法牴觸者無效**」

§172：「**命令與憲法或法律牴觸者無效**」

§112：「省得召集省民代表大會，依據省縣自治通則，
制定**省自治法**，但**不得與憲法牴觸**。」

1.2 確立憲法的權威解釋 (the Authoritative Interpretation of the Constitution)

§171-II：「法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之」

§114：「省自治法制定後，須即送司法院。司法院如認為有違憲之虞，應將違憲條文宣告無效。」

Cf. Marbury v. Madison (1803)

” *It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is.*

Those who apply the rule to particular cases must, of necessity, expound and interpret that rule.

If two laws conflict with each other, the Courts must decide on the operation of each.”

2. 守護憲法結構、保障基本人權

Q 既有§§ 114, 171-II (法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之)，何以又

§173：「**憲法之解釋，由司法院為之**」？

違憲審查（憲法解釋）不限於「規範控制」

♠ 參/五、建構「無漏洞」違憲審查

- **釋字585** / **釋字601**_理由書：

「憲法解釋之目的，在於確保民主憲政國家憲法之最高法規範地位，就**人民基本權利保障**及**自由民主憲政秩序**等憲法基本價值之維護，作成有拘束力之司法判斷」

Re: 自由民主憲政秩序（釋字499）

1. 民主共和國原則（將絕對的權力置於全民的控制下）

§1：「中華民國為民有、民治、民享之民主共和國」

§2：「中華民國之主權屬於國民全體」（國民主權原則）

2. 基本權亦為（表彰價值秩序之）客觀規範

Cf. GG §1-III：「（本章）以下所列基本權利，拘束立法、行政及司法權，而為直接有效之法規範。」（國家保護義務）

3. 權力分立原則（相互制衡&相互尊重）

四面向：垂直、水平、違憲審查 & 直接民主

4. 法治（國）原則（rule of law, É tat de droit, Rechtsstaat）

（將絕對的權力置於法規範的控制下） ≠ 人治

Cf. GG § 20-III：” Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.”

二、建置 (institutional design)

1. 專屬解釋權

= 集權式違憲審查 *centralized* constitutional review

1.1 違憲審查專屬司法院

§78：「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律與命令之權。」

憲法解釋 v. 統一解釋

增修 §5-IV：「司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外，並組成憲法法庭，審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項。」

1.2 司法院＝大法官合議制大法庭

§79-II：「司法院設大法官若干人，掌理本憲法第七十八條規定事項，由總統提名，經監察院同意任命之。」

增修§5-IV：「司法院設大法官十五人，並以其中一人為院長，一人為副院長，自中華民國九十二年起實施，不適用憲法第七十九條之規定。」

2. 列舉的抽象解釋（規範控制）權 （*specified* abstract constitutional review）

司法一元體系（概括審判權，階層分工關係）v.

司法二元體系（限定審判權，事務分工關係）
司法院組織定位

2.1 單純憲法疑義

中央或地方機關、立法委員現有總額三分之一以上，於行使職權，適用憲法發生疑義者，得聲請解釋憲法
（案件法 §§ 5-I-(1)前段 & 5-I-(3)前段）

抽象規範審查（abstrakte Normenkontrolle）

中央或地方機關、立法委員現有總額三分之一以上，於行使職權，適用法律發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法。
（案件法 §§ 5-I-(1)後段 & 5-I-(3)後段）

2.2 具體規範審查 (konkrete Normenkontrolle)[用語矛盾？]

終審法院（→法官）於審理案件時，對於應適用之法律，依其合理之確信，認為有牴觸憲法之疑義者，得以之為先決問題，裁定停止訴訟程序，並提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由，聲請大法官解釋（案件法 §5-II→ 釋字371, 572, 590）

2.3 機關權限爭議 (Organstreit)

中央或地方機關因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，得聲請大法官解釋（案件法 §5-I-(1)中段）

2.4 確定終局裁判準據法令違憲疑義

≠ (德國) 裁判憲法訴願

(Urteilsverfassungsbeschwerde)

人民、法人或政黨於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令（≠ 裁判本身認事用法）發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請大法官解釋（案件法 §5-I-(2)）

「命令」→ 最高法院之判例、決議（釋字 153, 154, 374, 420）

重要關聯性理論（解釋標的不受聲請意旨之拘束）♠ for what?

釋字445（與該具體事件相關聯且必要之法條）

釋字535（與該裁判準據重要關聯性之法條）

釋字664, 709（與系爭規定適用重要關聯之法條）

釋字737（與聲請解釋法條意涵相關聯之法條）

2.5 地方自治法規疑義

地制法 §30-V：自治法規與憲法、法律、法規命令、上級自治團體自治條例或該自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之。

地制法 §43-V：地方議會議決自治事項與憲法、法律、中央法規、縣規章有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之。

地制法 §75-VIII：地方行政機關辦理自治事項有無違背憲法、法律、中央法規、縣規章發生疑義時，得聲請司法院解釋之。

- 釋字527 (2001/06/15)

係指有監督權限之各級主管機關對決議事項或自治法規是否牴觸憲法、法律或其他上位規範尚有疑義，而未依各該條逕予函告無效，向本院大法官聲請解釋而言

- 釋字553 (2002/12/20)

行政院撤銷台北市政府延期辦理里長選舉之決定，涉及中央法規適用在地方自治事項時具體個案之事實認定、法律解釋，係行政處分，台北市政府有所不服，應循行政爭訟程序處理。

3. 列舉的具體解釋（個案裁判）權 （*specified* concrete constitutional review）

3.1 違憲政黨解散權

增修 §5-IV：司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外並組成憲法法庭審理政黨違憲之解散事項。

案件法 §19-I：政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散之。

3.2 總統彈劾案審理權 [違憲審查？]

增修 §2-X：立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

- 彈劾事由不明（違憲行為？失檢行為？）
- 審理程序不備（案件法迄未規定）

【表一】各國違憲審查制度比較

Nation Type	France Conseil constitutionnel	ROC (Taiwan) Judicial Yuan (Grand Justices)	Germany Bundes- verfassungsgericht	US Supreme Court
Essentials of Const' I Review	Abstract Review - Petition by President - Petition by Premier - Petition by Speaker of Assemblée nationale and Sénat - Petition by 60+ Members of Sénat - Petition by 60+ members of Assemblée nationale - Question prioritaire de constitutionnalité, QPC	Abstract Review Pure Doubts about the Meaning of a Constitutional Provision Norm Review - Organs Petition 1/3 Legislators + Petitioned - Judge Petition Disputes between State Organs Court Decision Norm Review - Local Ordinances Review Concrete Review - Dissolution of Parties - Impeachment Trial of President	Abstract Review Abstrakte Normenkontrolle - Petition by Federal or Land Government - Petition by 1/3 members + of Bundestag Konkrete Normenkontrolle (Judge Petitioned) Concrete Review Disputes between State Organs Verfassungsbeschwerde - Dissolution of Parties - Impeachment Trial of President	Concrete Review Decisions based upon cases or controversies



【表二】各國違憲審查制度比較

國別 類型		法國 憲法委員會	我國 司法院大法官	德國 聯邦憲法法院	美國 聯邦最高法院
具體 審查	抽象 審查 V.	抽象審查 ● 法律審查 ． 總統 ． 總理 ． 國會兩院議長 ． 六十名參議院議員連署 ● 違憲先決問題 ． 訴訟當事人聲請 (2008 修憲後)	抽象審查 ● 單純憲法疑義 ● 法令違憲疑義 ． 中央地方機關聲請 ． 立委三分之一聲請 ． 法官聲請 ● 憲法機關職權爭議解釋 ● 法令侵害基本人權疑義解釋 ● 地方自治疑義	抽象審查 ● 抽象規範審查 ． 聯邦、邦政府聲請 ． 眾議會議員三分之一聲請 ● 具體規範審查 (法官聲請) 具體審查 ● 機關權限爭議 ● 憲法訴願 ● 違憲政黨解散 ● 總統彈劾裁判	具體審查



解釋

具體審查

- 違憲政黨解散
- 總統彈劾案裁判？

三、程序

歷經三時期

1. 司法院大法官會議規則(1948/09/15~1958/07/20)
2. 司法院大法官會議法(1958/07/21~1993/02/02)
3. 司法院大法官審理案件法(1993/02/03~)

空間跨兩岸

大陸（南京）

釋字第1號（1949/01/06）& 釋字第2號（1949/01/06）

台灣（台北）

釋字第3號（1952/05/21）～ 釋字第752號（2017/07/28）

1. 司法院大法官會議規則 (1948/09/15~1958/07/20)

法定人數：2/3

可決門檻：1/2

聲請類型：機關聲請

2. 司法院大法官會議法 (1958/07/21~1993/02/02)

可決門檻：憲法解釋 $3/4 * 3/4$ ；統一解釋 $1/2 * 1/2$

♠ 可決門檻&憲法解釋之關聯 (【表四】)

聲請類型：機關聲請 + 人民聲請

不同意見書濫觴

3. 司法院大法官審理案件法 (1993/02/03~)

可決門檻：

憲法解釋：法律 $2/3 * 2/3$ ；

命令 $2/3 * 1/2$ 統一解釋： $1/2 * 1/2$

聲請類型：擴大機關聲請 ($1/3$ 立委 + 法院 (官)) + 人民聲

請個別意見書：協同意見書、不同意見書

貳、大法官解釋鳥瞰

(Overview of the Grand Justices' Interpretations)

一、回顧

【表三】 案件數總覽：解釋案 v. 聲請案

【表四】 大法官解釋案：憲法解釋 v. 統一解釋

【表五】 憲法解釋案：權力分立 v. 基本人權

【表六】 憲法解釋案聲請人：機關 v. 人民

【表七】 憲法解釋案機關聲請人分析

【表三】 案件數總覽：解釋案v. 聲請案



屆別 (任期)	解釋件數 (A) (案號)	當屆總收案件 (B)	解釋件數占總收案件百 分 (A/B= %)
第一屆 (37/07~47/08)	79 (No. 1~No. 79)	737	10.72%
第二屆 (47/09~56/08)	43 (No. 80~No. 122)	398	10.80%
第三屆 (56/09~65/09)	24 (No. 123~No. 146)	470	5.11%
第四屆 (65/10~74/09)	53 (No. 147~No. 199)	1198	4.42%
第五屆 (74/10~83/09)	167 (No. 200~No. 366)	2869	5.82%
第六屆 (83/10~92/09)	200 (No. 367~No. 566)	2534	7.89%

不分屆次 (92/10～ 105/10/31)	174 (No. 567～No. 740)	7110	2.45%
翁岳生法庭 (92/10～96/09/30)	67 (No. 567～No. 633)	1521	4.40%
賴英照法庭 (96/10/01～99/10/08)	48 (No. 634～No. 681)	1612	2.98%
賴浩敏法庭 (99/10/13～ 105/10/31)	59 (No. 682～No. 740)	3977	1.48%
許宗力法庭 (105/11/01～)	12 (No. 741～No. 752)		

【表四】大法官解釋案：憲法解釋v. 統一解釋



屆別 (任期)	件數 (起訖案號)	憲法解釋		統一解釋	
		件數	件數占當屆公布 解釋案件百分比	件數	件數占當屆公布 解釋案件百分比
第一屆 (37/07~47/08)	79 (No. 1~No. 79)	25	31.65% = 25/79	54	68.35% = 54/79
第二屆 (47/09~56/08)	43 (No. 80~No. 122)	8	18.60% = 8/43	35	81.40% = 35/43
第三屆 (56/09~65/09)	24 (No. 123~No. 146)	2	8.33% = 2/24	22	91.67% = 22/24
第四屆 (65/10~74/09)	53 (No. 147~No. 199)	32	60.38% = 32/53	21	39.62% = 21/53
第五屆 (74/10~83/09)	167 (No. 200~No. 366)	148	88.62% = 148/167	19	11.38% = 9/167
第六屆 (83/10~92/09)	200 (No. 367~No. 566)	191	95.50% = 191/200	9	4.50% = 9/191
不分屆次 (92/10~ 105/10/31)	174 (No. 567~No. 740)	167	95.98% = 167/174	7	4.02% = 7/174

翁岳生法庭 (92/10~96/09/30)	67 (No. 567~No. 633)	66	98.50% = 66/67	1	1.50% = 1/67
賴英照法庭 (96/10/01~ 99/10/08)	48 (No. 634~No. 681)	46	95.83% = 46/48	2	4.17% = 2/48
賴浩敏法庭 (99/10/13~ 105/10/31)	59 (No. 682~No. 740)	55	93.22% = 55/59	4	6.78% = 4/59

【表五】 憲法解釋案：權力分立v. 基本人權



屆別 (任期)	憲法解釋案件數 (起訖案號)	政府體制		基本權利	
		件數	占憲法解釋 案件百分比	件數	占憲法解釋 案件百分比
第一屆 (37/07~47/08)	25 (No. 1~No. 79)	16	64.00%	9	36.00%
第二屆 (47/09~56/08)	8 (No. 80~No. 122)	5	62.50%	3	37.50%
第三屆 (56/09~65/09)	2 (No. 123~No. 146)	1	50.00%	1	50.00%
第四屆 (65/10~74/09)	32 (No. 147~No. 199)	9	28.13%	23	71.87%
第五屆 (74/10~83/09)	148 (No. 200~No. 366)	30	20.27%	118	79.73%
第六屆 (83/10~92/09)	191 (No. 367~No. 566)	23	12.04%	168	87.86%
不分屆次 (92/10~ 105/10/31)	167 (No. 567~No. 740)	10	5.99%	157	94.01%
翁岳生法庭 (92/10~ 96/09/30)	66 (No. 567~No. 633)	6	9.01%	60	91.04%

賴英照法庭 (96/10/01～ 99/10/08)	46 (No. 634～No. 681)	1	2.08%	45	97.91%
賴浩敏法庭 (99/10/13～ 105/10/31)	55 (No. 682～No. 740)	3	5.45%	52	94.55%

【表六】憲法解釋案聲請人：機關聲請v. 人民聲請



* 釋字第739號解釋同時有人民及法官聲請，計入人民聲請

屆別 (任期)	憲法解釋案件數 (起訖案號)	機關聲請		人民聲請	
		件數	占憲法解釋案件百分比	件數	占憲法解釋案件百分比
第一屆 (37/07~47/08)	25 (No. 1~No. 79)	25	100%		
第二屆 (47/09~56/08)	8 (No. 80~No. 122)	7	87.50%	1	12.50%
第三屆 (56/09~65/09)	2 (No. 123~No. 146)	2	100%	0	0.00%
第四屆 (65/10~74/09)	32 (No. 147~No. 199)	5	15.62%	27	84.38%
第五屆 (74/10~83/09)	148 (No. 200~No. 366)	33	22.30%	115	77.70%
第六屆 (83/10~92/09)	191 (No. 367~No. 566)	37	19.37%	154	80.63%
不分屆次 (92/10~105/10/31)	167 (No. 567~No. 740)	32	19.16%	135	80.84%
翁岳生法庭 (92/10~)	66 (No. 567~No. 633)	16	24.24%	50	75.76%

96/09/30)					
賴英照法庭 (96/10/01～ 99/10/08)	46 (No. 634～No. 681)	11	23.91%	35	76.09%
賴浩敏法庭 (99/10/13～ 105/10/31)	55 (No. 682～No. 740)	5	9.09%	50	90.91%

【表七】憲法解釋案機關聲請人分析



屆別 (任期)	法官聲請		1/3立法委員聲請		其他機關聲請	
	件數	占憲法解釋案件百分比	件數	占憲法解釋案件百分比	件數	占憲法解釋案件百分比
第一屆 (37/07~47/08)					25	100.00%
第二屆 (47/09~56/08)					7	100.00%
第三屆 (56/09~65/09)					2	100.00%
第四屆 (65/10~74/09)					3	100.00%
第五屆 (74/10~83/09)	0	0.00	0	0.00%	33	100.00%
第六屆 (83/10~92/09)	7	18.92%	15	40.54%	15	40.54%
不分屆次 (92/10~105/10/31)	17	53.13%	8	25.00%	7	21.87%
翁岳生法庭 (92/10~96/09/30)	5	31.25%	6	37.50%	5	31.25%
賴英照法庭 (96/10/01~)	9	81.82%	1	9.09%	1	9.09%

99/10/08)						
賴浩敏法庭 (99/10/13～ 105/10/31)	3	60.00%	1	20.00%	1	20.00%

貳、大法官解釋鳥瞰

二、現時困境 速率降低、意見分歧

【表八】歷屆大法官作成解釋速率

【表九】歷屆大法官解釋意見分歧程度（粗估）

【表八】歷屆大法官作成解釋速率



屆別 (任期)	件數 (起訖案號)	任期 (年)	每年平均作成 解釋案件數
第一屆 (37/07~47/08)	79 (No. 1~No. 79)	9	8.78 = 79/9
第二屆 (47/09~56/08)	43 (No. 80~No. 122)	9	4.78 = 43/9
第三屆 (56/09~65/09)	24 (No. 123~No. 146)	9	2.67 = 24/9
第四屆 (65/10~74/09)	53 (No. 147~No. 199)	9	5.89 = 53/9
第五屆 (74/10~83/09)	167 (No. 200~No. 366)	9	18.56 = 167/9

	366)		
第六屆 (83/10～92/09)	200 (No. 367～No. 566)	9	22. 22 = 200/9
不分屆次 (92/10～ 105/10/31)	174 (No. 567～No. 740)	13. 09	13. 29 = 174/13. 09
翁岳生法庭 (92/10～96/09/30)	67 (No. 567～No. 633)	4. 00	16. 75 = 67/4
賴英照法庭 (96/10/01～99/10/08)	48 (No. 634～No. 681)	3. 03	15. 84 = 48/3. 03
賴浩敏法庭 (99/10/13～105/10/31)	59 (No. 682～No. 740)	6. 06	9. 73 = 59/6. 06
許宗力法庭 (105/11/01～)	12 (No. 741～No. 752)		

【表九】 歷屆大法官解釋意見分歧程度（粗估）



屆別 (任期)	憲法解釋			統一解釋		
	個別意見書 件數(A)	憲法解釋 件數(B)	個別意見書所占 比例(A/B %)	個別意見書 件數(C)	統一解釋 件數(D)	個別意見書所 占比例(C/D %)
第一屆 (37/07~47/08)	NA	NA		NA	NA	
第二屆 (47/09~56/08)	2	2	100.00%	33	27	122.22%
第三屆 (56/09~65/09)	4	2	200.00%	32	18	177.78%
第四屆 (65/10~74/09)	27	18	150.00%	32	17	188.24%
第五屆 (74/10/02~76/08/27) (No. 200~218)	7	5	140.00%	3	2	150.00%

(76/08/28~83/10/01) (No. 219~366)	92	56	164. 29%	10	8	125. 00%
第六屆 (83/10~92/09)	161	87	185. 05%	15	2	125. 00%
不分屆次 (92/10~105/10/31)	616	167	368. 86%	40	7	571. 43%
翁岳生法庭 (92/10~96/09/30)	106	66	160. 60%	2	1	200. 00%
賴英照法庭 (96/10/01~99/10/08)	126	46	273. 91%	8	2	400. 00%
賴浩敏法庭 (99/10/13~ 105/10/31)	384	55	698. 18%	30	4	750. 00%

參、癥結(診斷) & 對策(處方)

Why?

Warum?

Pourquoi?

Q 審查程序基本相同（案件法1993~未修正），
結果何以出現重大差異？

一、不得連任 & 間隔任期 $\Longrightarrow$ 經驗不易傳承、默契難以培養

增修 §5

I. 司法院設大法官 **十五人**，並以其中 **一人為院長、一人為副院長**，由總統提名，經立法院同意任命之，自中華民國九十二年實施，不適用憲法第七十九條之規定。司法院大法官 **除法官轉任者外**，**不適用**憲法第八十一條及有關 **法官終身職待遇**之規定。

大法官兼院長，非院長兼大法官！（釋字530）

Q 大法官同工不同酬？[釋字499] 影響？

II. 司法院大法官 **任期八年**，不分屆次，個別計算，並 **不得連任**。但 **並為院長、副院長之大法官**，不受任期之保障。

Q 院長「不受任期保障」，仍有「大法官」任期保障？

Q 不得「連任」，可「再任」？ $\Longrightarrow$ 影響？

III. 中華民國九十二年總統提名之大法官，其中 **八位**大法官，含院長副院長，任期四年，**其餘**大法官任期為八年，不適用前項任期之規定

Q 何以改採 **間隔任期**，每 **四年**改選 **半數**（8/7 $\rightarrow$ 4/5/2/4 $\rightarrow$ 4/7/4 $\rightarrow$?）

一、不得連任 & 間隔任期 $\Longrightarrow$
經驗不易傳承、默契難以培養

對策：

1. 不修憲_嚴守間隔任期設計
每 4 年更換半數 (8/7)，遇缺不補 or 遞補者任期同原任期

司法院組織法 2015 年修正，刪除原 §5-III (大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日止)
2. 修憲_間隔任期合理化
 - 2.1 延長任期(至 12 年)，每 4 年更換 1/3 (5/15) $\Longrightarrow$ 提升效率
 - 2.2 延長任期(至 12 年)並減少人數(至 9 人)，每 4 年更換 1/3 (3/9) $\Longrightarrow$ 提升效率 & 改進組織

二、超大法庭 & 超低效率的合議審查

1. 改採主筆顯名 & 主文評議，改進審議方式
全體大法官逐字審議解釋全文（解釋文 & 理由書）
循名責實（確立誘因）、傳閱整合（理由形成）
2. 降低可決門檻
主文（解釋文）評決：以一般多數決為原則；
受理：改採「次多數決原則」（US “rule of four”）
2013 修法草案（不對稱門檻： $2/3 * 2/3$ 違憲）商榷
3. 改採強制代理，一律行言詞辯論
建立舉證責任、強化背景理解、充實論理基礎
4. 強化幕僚（4 助理 + 1 秘書）
目標：每個大法官辦公室，皆具備獨立辦案能力；
司法院組織改造：行政機關 $\longrightarrow$ 審判機關

三、人能弘道，非道弘人

梅貽琦：所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也！

⇒ 大法官者，才德兼備、器識恢弘之士也！

3.1 大法官資格 & 選任

舊司法院組織法 §4（五款）：法官 & 學者

104年修正 §4（六款）：（法官、檢察官、律師）& 學者
各款出身不得逾總數三分之一

❏ 兼顧多樣性（diversity）與專業性（expertise）？

❏ 改進提名 & 審查程序？[審查方式改變，個別責任加重]

3.2 大法官保障

法官法的弔詭

保障平等退職，俾能全心奉獻，無後顧之憂

孔子：「君子固窮」；孟子：「無恆產而有恆心者，惟士為能」

四、司法院組織定位

司法院＝最高法院？

司法院(大法官)與法院(法官)如何分工？

§77：司法院為國家**最高司法機關**，掌理民事、刑事、行政訴訟之**審判**及公務員之懲戒。

§78：司法院**解釋憲法**，並有**統一解釋法律與命令**之權。
(憲法解釋 v. 統一解釋)

⇒ **司法院得不掌理審判？** **司法院定位問題由來**

§79：司法院設**院長、副院長**各一人，由總統提名，經監察院同意任命之。

司法院設**大法官**若干人，**掌理本憲法第七十八條規定事項**，由總統提名，經監察院同意任命之。

⇒ **司法院＝司法行政院？** (非為大法官之院長，負責？)

參、癥結 & 對策 /四、司法院組織定位未決

Option 1: 一元多軌模式

司法院＝法官（§77各種訴訟）＋大法官（§78憲法解釋&統一解釋）
＋院長、副院長（非大法官或法官，負責司法行政）
政治協商會議「憲草原則」（四）：

司法院即為國家最高法院，不兼管司法行政，由大法官若干人組織之，大法官由總統提名，經監察院同意任命之，各級法官須超出於黨派之外。

司法院組織法（36/03/31，未施行）

司法院設大法官會議，以大法官9人組織之（§3）

司法院各審判庭與大法官間之關係？（§4）

司法行政之內涵？（§5）

Option 2: 多元多軌模式

司法院 = 大法官 (§78 憲法解釋 & 統一解釋) +
院長、副院長 (司法行政, 不具大法官身分)
下轄各級法院 = 法官 (§77 各種審判)

司法院組織法 (36/12/25)

司法院設大法官會議, 以大法官17人組織之? (§3)
大法官「會議」日益「法院」化
院長任務模糊化 (§6 刪除原 §5 「之行政事務」)

Option 3: 一元單軌模式

司法院＝大法官（§78憲法解釋 & 統一解釋 + §77終審訴訟審判）
院長、副院長（由大法官並任，兼掌司法行政）

「全國司法改革會議」（88年7月）

- 決議：「司法院審判機關化」
- 司法院公布「三階段組織改造時程」（1999/07/26）

現制（多元多軌模式）【圖一】

- 釋字530（90/10/15）（最高審判機關始得兼掌司法行政）
 - 第一階段：一元多軌模式（92/10/01~96/12/31）【圖二】
 - 第二階段：一元多軌模式（97/01/01~99/12/31）【圖三】
 - 第三階段：一元單軌模式（100/01/01~）【圖四】

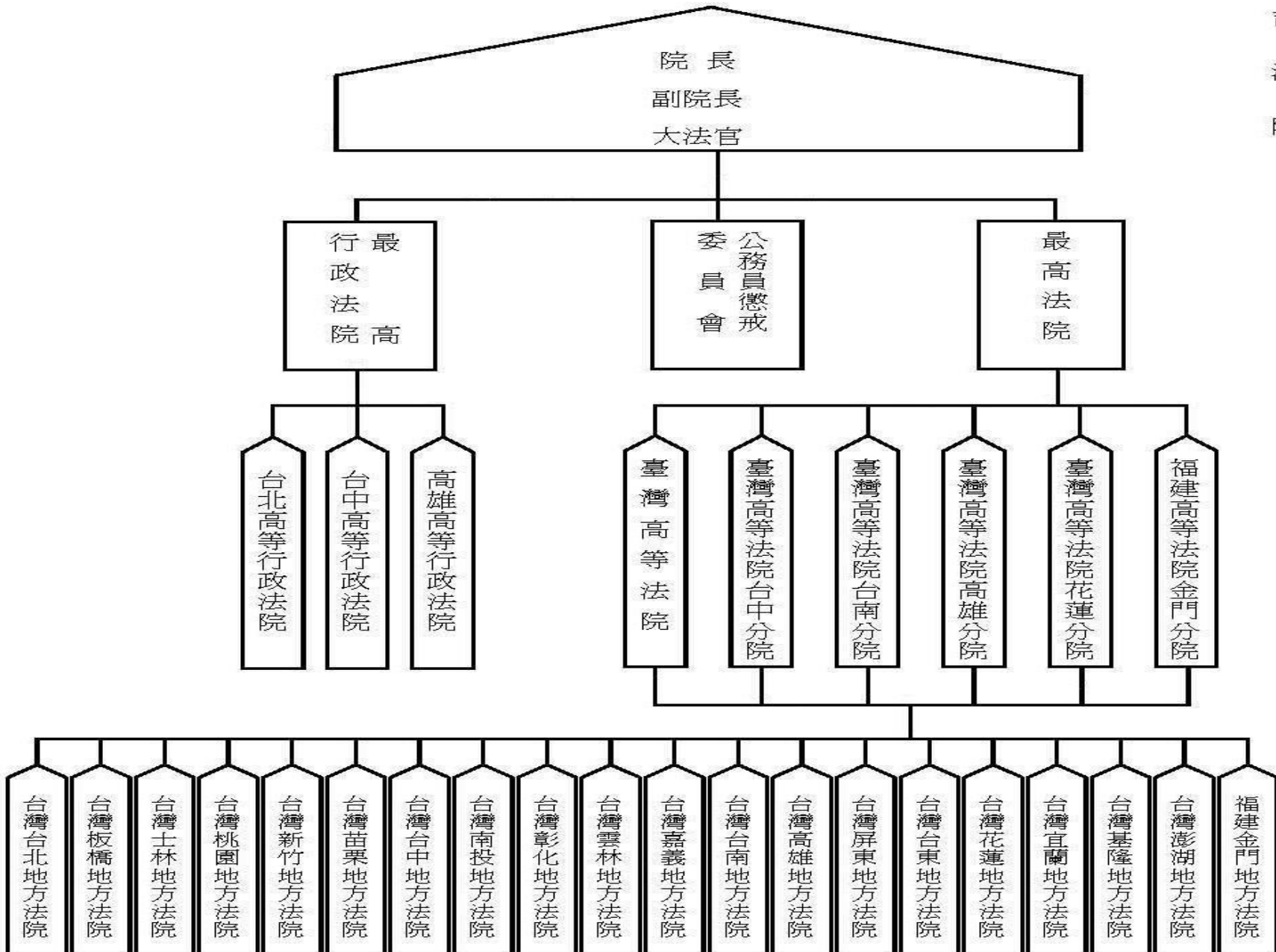
⇒ 未果，Why?

(多元多軌)

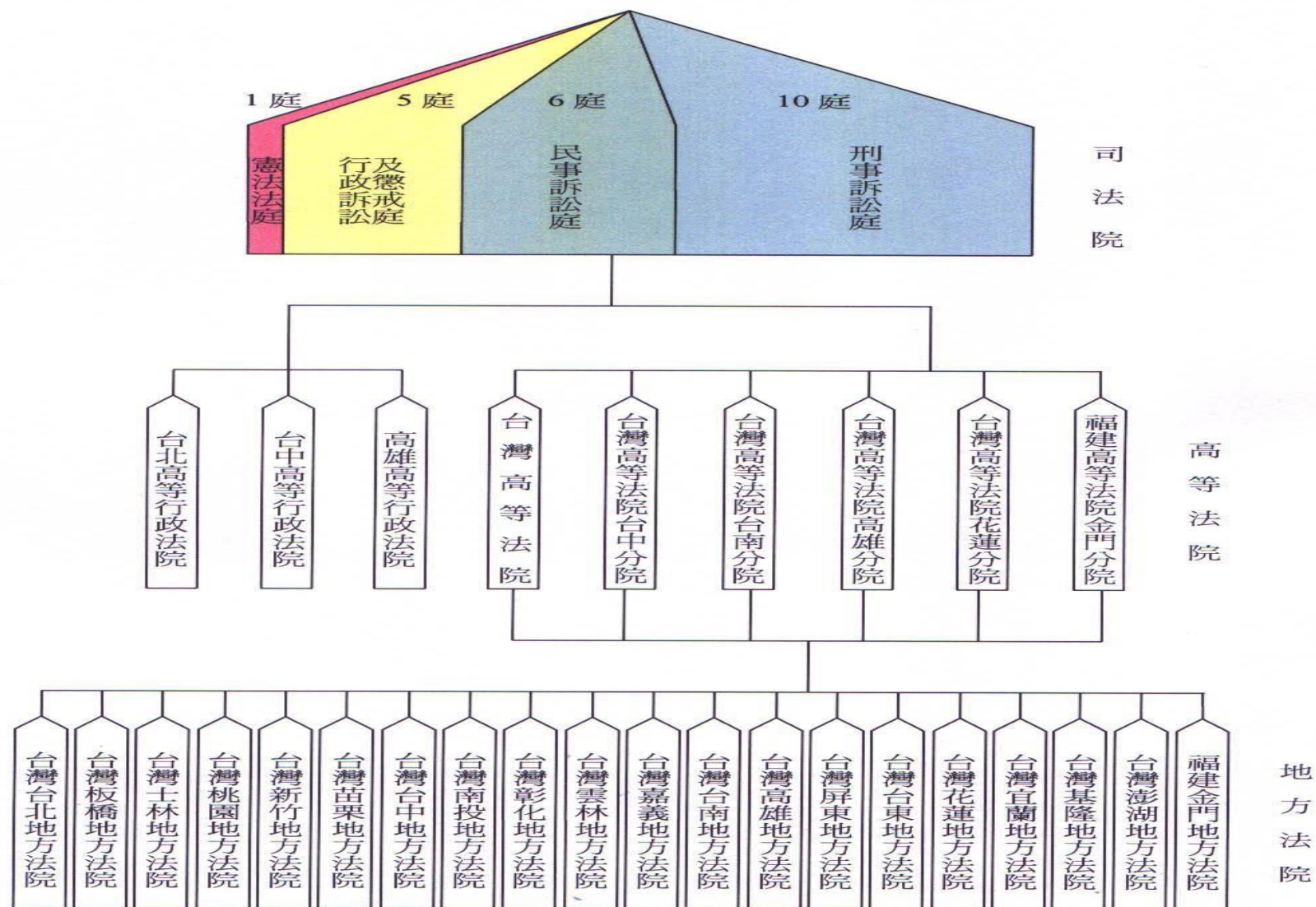
司
法
院

高
等
法
院

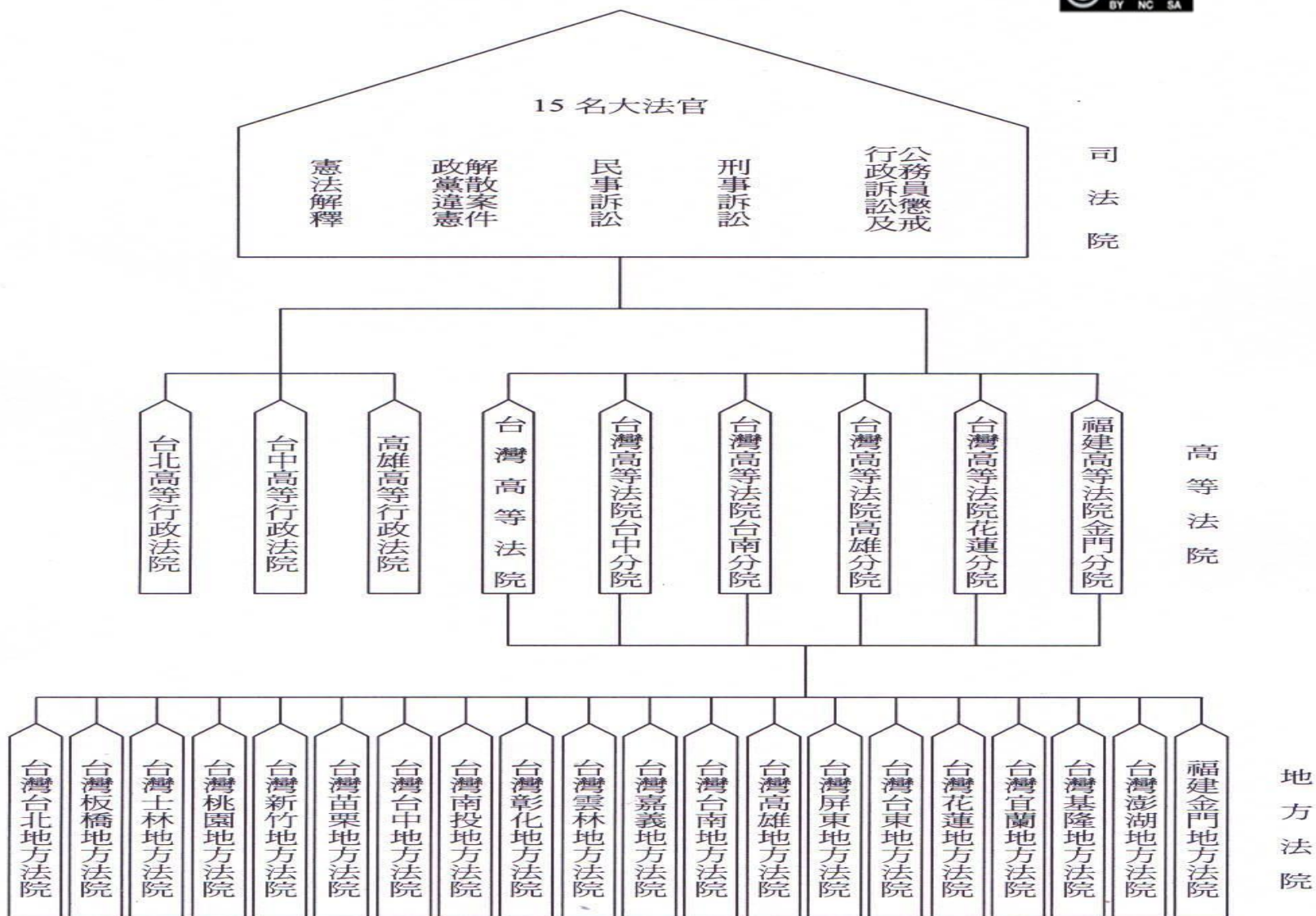
地
方
法
院



圖二：第一階段司法院組織改造
(一元多軌：92/10/01~96/12/31)



圖四：第三階段司法院組織改造
(一元單軌：100/01/01~)



司改國是會議（2017/02~08）：改良式多元多軌模式
引進**裁判憲法訴願**（2017/03/06第二分組決議）
終審法院：法官縮編（至21人）& **選任方式**改變
（2017/04/24第二分組決議）：

司法院長提名3倍人選，交法官遴選委員會遴薦2倍人選，
呈報總統圈選。仍為終身職，70歲退休。

- Q 為何縮編？[]與選任方式 何關？
- Q 同為終身職（職業）法官，何以選任方式不同？
- Q 總統之任命，無需經立法院同意？
- Q 旨在建立「**全民信賴公正的司法**」？
強化法官的政治可問責性(political accountability)？
其他？

五、違憲審查漏洞

法院近用(admissibility, justiciability)
誰在何時(如何要件下)得發動違憲審查?

概括個案裁判(司法一元體系) v.

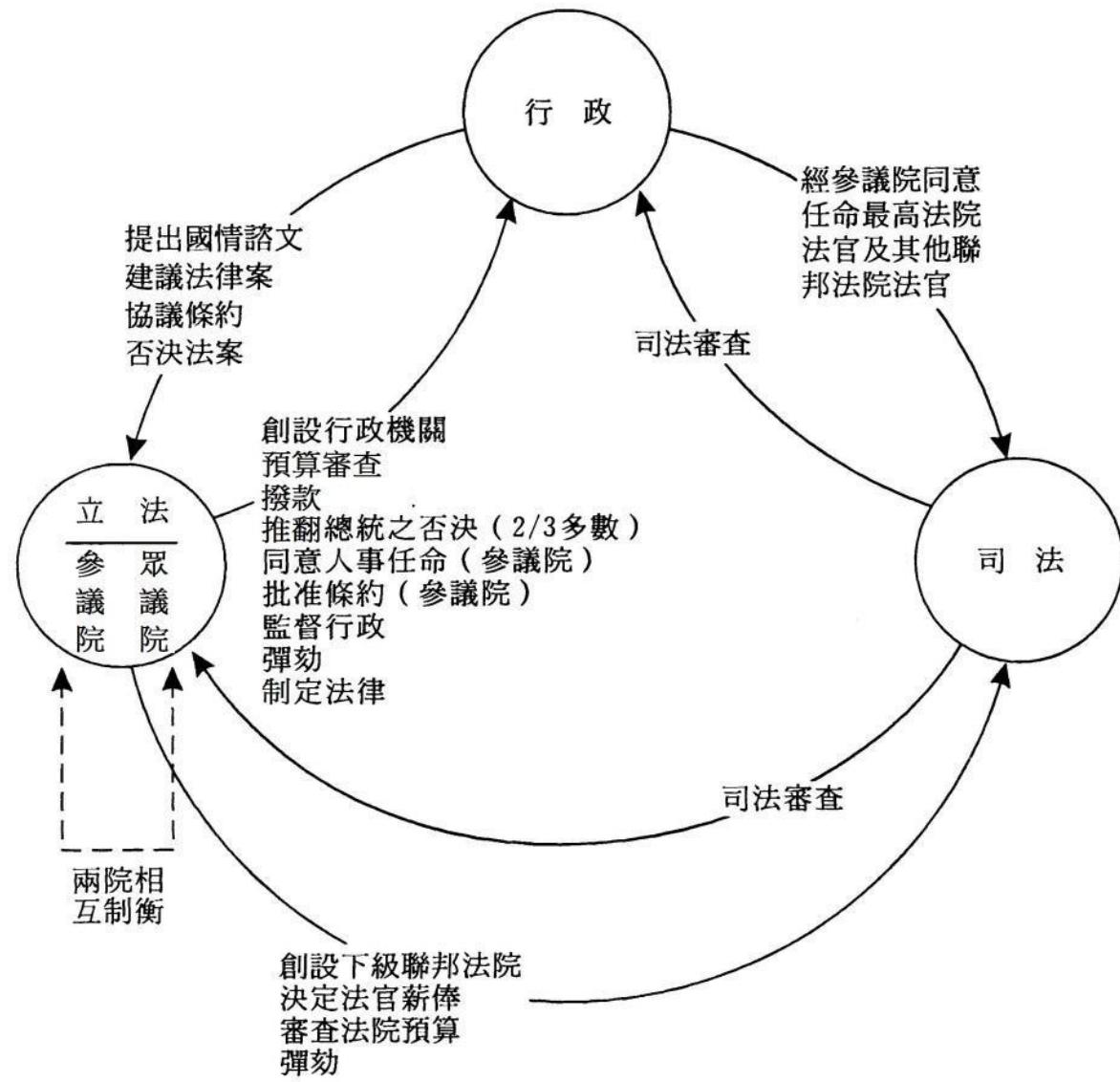
限定抽象&具體解釋(司法二元體系)

抽象違憲審查階段任務(宏揚憲政理念、闡明憲法疑難)
已大體完成，如何就社會重大爭議(hard cases)，
適時作成終局裁判，定分止爭，為今後之嚴峻挑戰！

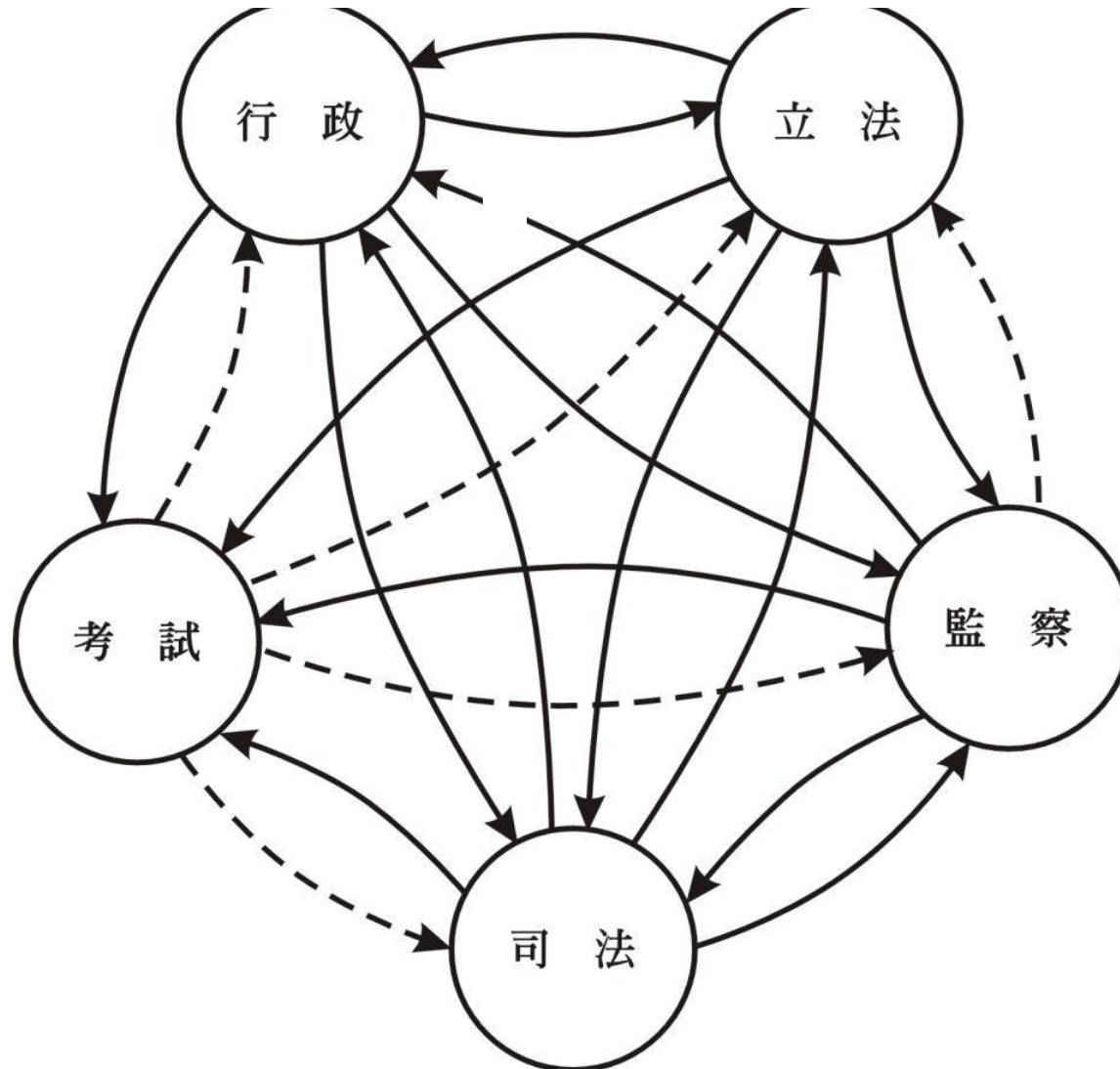
Q 同婚(釋字748)? 年改? 不當黨產? 前瞻審查? ...

Beyond *abstract* judicial review of
constitutionality & Beyond *concrete* judicial
review of *legality* (釋字 742)

【圖五】三權分立、相互制衡



【圖六】五權分治、平等相維



參、問題與對策 / 五、違憲審查漏洞猶存

1. 引進（裁判）憲法訴願：

從抽象審查轉進具體審查的第一步

Urteilsverfassungsbeschwerde = 人民得以**確定終局裁判**本身認事用法**侵害基本權**為由，聲請大法官直接廢棄原判決

- 人民聲請釋憲已成大法官憲法解釋之最大宗
- 建構無漏洞的憲法權利保護，符合全民對司法的期待
- 現行折衷式憲法訴願」與「憲法訴願」僅一步之遙 確定終局裁判適用法令違憲與裁判見解違憲，實際殆難截然劃分

Ex. **釋字242, 736, 747**（形式上為法規審查，實際變更確判見解）

2. 回歸「個案裁判」符合司法權本質

- 與其單純仰賴「**司法自制**」(judicial self-restraint)，不如建立「**案件或爭議要件**」(case or controversy requirement)
- **權力分立動態平衡理論**
違憲審查乃**權力部門間持續性的憲法對話** (ongoing constitutional discourse)，旨在促進「**思辨民主**」(deliberative democracy) 違憲審查**應注意保留立法裁量空間，避免侵奪立法權；立法規範應避免侵害違憲審查核心，或危害審判獨立。**
- 司法院為國家最高司法機關＝
以**裁判憲法爭議**為主要任務的大法官合議制**憲法法院**；
視施行成效，決定是否進一步改制為**最高法院**
- 必要配套：**移審令**(certiorari)；而非改變終審法官之任命

Q 引進裁判憲法訴願制度，將破壞司法院與下屬法院之分工關係？

Q 引進裁判憲法訴願制度，司法院將難以負荷（案件激增）？

結語



黃梨洲(宗義)：

「三代以上，藏天下於天下；三代以下，藏天下於筐篋」



「三代以上有法，三代以下無法」



頂天立地，俯仰無愧；
胸懷萬有，智周萬物

湯德宗大法官

The Honorable Justice Dennis T. C. Tang

學經歷：

美國紐約大學(NYU)法學院客座特聘教授

中央研究院特聘研究員暨法律學研究所創所所長

國立台灣大學國發所暨政治系兼任教授

日本東京大學(Tokyo U.)法學部客座教授

德國科隆大學(Universität zu Köln)鴻博(AvH)訪問學者

美國杜蘭大學(Tulane U.) 法學博士

(S. J. D.) 美國哈佛大學(Harvard U.) 法

學碩士(LL. M.) 國立台灣大學法律研究所

碩士

國立台灣大學法律系 學士



代表作：

《憲法結構與動態平衡：權力分立新論 卷一》(增訂四版, 2014)

《違憲審查與動態平衡：權力分立新論 卷二》(增訂四版, 2014)

《對話憲法・憲法對話：湯德宗憲法有聲書》(上冊, 增訂三版2015; 下冊, 增訂三版2016)

<http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ocw/cou/105S104>

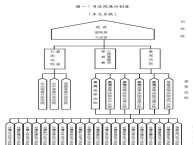
《行政程序法論：論正當行政程序》(增訂二版, 2005)

ENVIRONMENTAL LAW AND ENFORCEMENT IN THE ASIA-PACIFIC RIM 435~486 (Sweet & Maxwell, 2002).

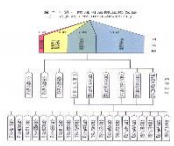
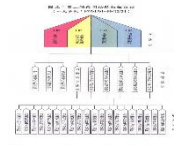
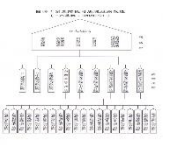
版權聲明

頁	作品	版權標章	作品/來源
2及57			本作品由「湯德宗」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
15	【表一】各國違憲審查制度比較		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
16	【表二】各國違憲審查制度比較		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
21	【表三】案件數總覽：解釋案V. 聲請案		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
23	【表四】大法官解釋案：憲法解釋V. 統一解釋		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。

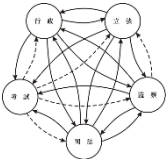
版權聲明

頁	作品	版權標章	作品/來源
25	【表五】憲法解釋案：權力分立 v. 基本人權		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
27	【表六】憲法解釋案聲請人：機關 v. 人民		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
29	【表七】憲法解釋案機關聲請人分析		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
32	【表八】歷屆大法官作成解釋速率		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
34	【表九】歷屆大法官解釋意見分歧程度（粗估）		本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
45			本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。

版權聲明

頁	作品	版權標章	作品/來源
46			本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式 分享 3.0 台灣」許可協議。
47			本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式 分享 3.0 台灣」許可協議。
48			本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式 分享 3.0 台灣」許可協議。
51			本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式 分享 3.0 台灣」許可協議。

版權聲明

頁	作品	版權標章	作品/來源
52			本作品由國立台灣大學湯德宗教授採用創用 CC 「姓名標示- 非商業性-相通方式分享 3.0 台灣」許可協議。
56			https://www.flickr.com/photos/wangleon/131329154 Source: Flickr /Author: wang leon/ Name: 天下为公匾額 -总统府大堂正中橫梁上挂孙中山手书“天下为公”匾額 本作品採用創用 CC 「姓名標示 2.0 通用」許可協議。2018/06/16visited
56	「三代以上，藏天下於天下；三代以下，藏天下於筐篋」		明末清初，《明夷待訪錄》，作者黃宗羲。本作品為公共財。
56	「三代以上有法，三代以下無法」		明末清初，《明夷待訪錄》，作者黃宗羲。本作品為公共財。